

1500419-49.2019.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500419-49.2019.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500419-49.2019.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS AURÉLIO DA SILVA ALVES

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

MARCOS AURÉLIO DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 19h40min, na Rua Álvaro dos Santos, nº 35, neste Município e Comarca de Marília, guardava, para fins de tráfico, 26 (vinte e seis) porções de maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo de fls. 19/21 e fls. 60/62.

Preso em flagrante delito, houve a concessão de liberdade provisória mediante condições (fls. 38/40). O réu foi notificado (fls. 100/101) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 106/107). A denúncia foi recebida em 12/3/2021 (fls. 110/112) e o réu foi citado e intimado (fl. 163). Na audiência realizada em 27/10/2021, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e três testemunhas de defesa. Em audiência presencial o réu foi interrogado (fls. 172/173).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da ação. Na dosimetria da pena ressaltou a fixação da pena base no mínimo legal. Na segunda fase pleiteou a atenuante da menoridade relativa, a ausência de agravantes, bem

como causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase. Por fim, apontou que o regime de cumprimento deve ser o fechado, sendo inviável a substituição por pena restritiva de direitos (fls. 177/185).

A defesa argumentou, preliminarmente, apontando a ilicitude das provas obtidas mediante a revista pessoal do acusado e a violação de seu domicílio. Além disso, pleiteou a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal. Na dosimetria sustentou que seja aplicado o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fixação do regime aberto e operada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, observando-se o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

Preliminarmente, a Defesa argumenta que a prova obtida é ilícita sustentado a tese na invasão de domicílio e revista pessoal.

Contudo, tal pleito deve ser rejeitado eis que não ficou demonstrado qualquer abuso na diligência policial.

Como apurado, os policiais militares, durante patrulhamento, somente após a atitude suspeita do acusado de esquivar-se tão logo avistou a viatura e dispensar uma porção de maconha na varanda da casa, é que adentraram a residência, caracterizando nitidamente a situação de flagrância.

Todas as circunstâncias alinhadas, como a própria denúncia apontando o local como ponto de tráfico, revelam a regularidade da prisão e da revista pessoal, da qual não se tem notícia de abuso, limitando-se a um procedimento rotineiro.

Outrossim, a entrada dos policiais no local, como descrito, se deu com fundada suspeita e em situação de flagrância, que prescinde de autorização judicial. A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...)

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/R0, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. Na hipótese dos autos, a entrada dos policiais na residência do paciente, após denúncia anônima de que na casa estaria

sendo praticado o tráfico de drogas, deu-se com o prévio consentimento do paciente, o que afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão. (Habeas Corpus nº 608.558/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1/12/2020).

No mais, a existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelos laudos de exame químico-toxicológico (constatação provisória - fls. 19/21) e laudo definitivo (fls. 60/62), este atestando a natureza da substância apreendida (tetrahidrocannabinol) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

A testemunha Anselmo Bernardo da Luz, policial militar, declarou que havia informações de que no local dos fatos era praticado o comércio de entorpecentes. Dessa forma, no dia dos fatos, ele e seu colega de farda estavam realizando um patrulhamento visando coibir esta atividade. Visualizaram o réu próximo a uma motocicleta. Ao perceber que iria ser abordado, ele ingressou na residência. Já na varanda da sua casa dispensou um invólucro contendo maconha. Eles conseguiram abordá-lo e encontraram mais porções do entorpecente no interior da residência, além de objetos relacionados ao tráfico, tais como um prato aparentemente com resquícios de droga, papel filme e balança de precisão. Não conhecia o réu e nunca teve problemas com ele.

A testemunha Bruno Abrão Barboza, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu conversando com outra pessoa, posteriormente identificada como seu tio. Ao ver os policiais o réu saiu correndo para o interior da sua casa e fechou o portão com uma chave. Ao perceber a movimentação estranha, os policiais saíram em seu encalço e, ainda no exterior da casa, encontraram uma porção de maconha. Eles encontraram a chave do imóvel e, na companhia da mãe do réu, ingressaram na casa, onde foram encontradas mais porções de maconha sobre um guarda-roupas. Também havia uma balança de precisão e papel filme. O réu disse que o entorpecente era para o seu consumo.

O informante Jair José de Souza, avô do réu, declarou não ter presenciado os fatos. Contudo sabe que o réu trabalha com seu pai.

A testemunha de defesa Edinéia Fátima Paes de Oliveira declarou que não estava presente no local dos fatos. Afirmou que o réu trabalha com o pai como servente.

A informante Cristiane da Silva de Souza Alves, mãe do réu, declarou ter chegado no local dos fatos quando os policiais estavam realizando a abordagem. Após ingressarem no imóvel os policiais saíram e apresentaram para ela o entorpecente encontrado. Afirmou que o réu trabalhava como servente de pedreiro com o pai e, por um período, trabalhou na fábrica da Nestle.

O réu Marcos Aurélio da Silva Alves, interrogado, declarou que era proprietário do entorpecente encontrado na sua posse. Contudo, a droga para seu consumo. Os rolos de plástico filme e a balança encontrada em sua residência eram utilizados na fabricação e embalagem de bolos e doces que ele vendia no centro da cidade.

Não obstante os argumentos defensivos, a atividade delitiva foi corroborada pela existência de elementos bastantes que demonstram que o acusado era proprietário das drogas e que as porções de entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que havia denúncia de tráfico no local; b) a atitude suspeita do acusado que além de fugir da abordagem, dispensou o entorpecente que trazia consigo; c) a

forma de acondicionamento da droga apreendida, embaladas individualmente e prontas para entrega ao consumo de terceiros; d) a apreensão de balança de precisão, rolos de filme plástico e embalagens tipo "saco zipper" semelhantes àquelas que acondicionavam o entorpecente; e) a quantia em dinheiro, em notas diversificadas, encontradas na moto de propriedade do sentenciado.

A acusação, por sua vez, encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos, descrevendo a diligência desde o momento que a viatura foi avistada pelo réu até a apreensão de entorpecentes no interior da residência.

Já a negativa do acusado restou isolada nos autos e não há qualquer evidência de que a droga se destinava ao consumo.

A par disso, nenhuma das testemunhas arroladas pelo acusado, inclusive parentes próximos (mãe e avô), mencionou ser ele usuário de droga. E mesmo que o réu seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

Desta forma, inviável o acolhimento da tese sustentada pela defesa de desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Além disso, enquanto o réu afirmou que os rolos de papel filme e balança destinavam-se aos doces que vendia no centro da cidade, a testemunha de defesa e seus familiares disseram em Juízo que ele trabalhava como servente de pedreiro, denotando a completa fragilidade de sua versão em Juízo.

Portanto, conclui-se pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Com relação à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em tela. Verifico que, apesar da quantidade dos entorpecentes apreendidos não ser expressiva, conforme consta nos documentos encartados aos autos, o réu ostenta antecedentes infracionais e, inclusive, cumpriu medida socioeducativa de semiliberdade e liberdade assistida por atos infracionais análogos a delitos patrimoniais (fls. 8/9 – peças sigilosas). Embora tais feitos da Vara da Infância e Juventude não permitam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria ou signifiquem reincidência (artigos 59 e 64 do Código Penal c/c Súmula 444 do STJ), são dados idôneos para afastar a minorante, porquanto comprovam a dedicação às atividades delituosas desde a adolescência e a habitualidade em praticar fatos tipificados como crime. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade da redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas, conforme atos infracionais praticados quando adolescente. Precedentes do STJ. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido. – Apelação nº 1500768-90.2020.8.26.0472, Rel. Reinaldo Cintra, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28/2/2021.

"(...) Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas (...)" - AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJE 04/05/2020.

“(...) A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à prática delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto (...)” - AgRg no HC 544.100/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/02/2020.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei n. 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque apesar da quantidade de entorpecente não se justifica o agravamento da pena, pois o réu é primário (fls. 130/132). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante. Reputo presente a atenuante da menoridade relativa (réu menor de 21 anos na data dos fatos – fl. 23), contudo, não tem esta o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo legal, permanecendo a pena tal como fixada na primeira fase da dosimetria.

Não há causas de aumento de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a quantidade de droga e a apreensão de apetrechos e balança de precisão, além de dinheiro sem a comprovação de origem lícita e os registros na Vara da Infância, são indicativos de que o acusado se dedica a atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do redutor.

Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO MARCOS AURÉLIO DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, em razão do montante da pena fixada, da gravidade em concreto do delito e dos registros apurados junto à Vara da Infância e Juventude, aliados à ausência de comprovação de atividade laborativa lícita.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

Considerando que foi concedida a liberdade provisória ao réu e ante a ausência de

elementos concretos a embasar a necessidade da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens, consistentes: I) no depósito judicial de fl. 65/66 e II) nos objetos descritos na relação de remessa nº 79/2020 de fl. 72.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o expresse permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Oficie-se, oportunamente, para a Seção de Armas e Objetos da Comarca.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA